

1500206-52.2020.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... do caráter permanente do delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, fica repelida referida tese defensiva pelos motivos expostos alhures.

Neste sentido, aliás, forte a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-52.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-52.2020.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALVES DE MORAES JUNIOR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

MARCOS ALVES DE MORAES JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", e art. 33, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, porque, na data de 16 de janeiro de 2020, por volta das 12h30min, na Rua Salvador Bianchi, nº 26, Jardim

Caieiras, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, tinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, uma porção de Cocaína, na forma de "crack", pesando 5,81g, e três tabletes de maconha, pesando 307,19g, e vendeu duas porções desta última droga, pesando 1,23g; fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que tinha em depósito produtos químicos destinados à preparação de drogas, consistentes em 05 frascos de vidro contendo acetona.

Notificado, foi apresentada resposta escrita. A denúncia foi recebida. O acusado foi devidamente citado (fls. 181).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas devidamente arroladas, procedendo-se ao interrogatório (mídia digital).

Devido ao teor da laudo de fls. 240/242, a denúncia foi aditada às fls. 243, para que o termo "acetona" seja substituído por "cloroeto de metileno/diclorometano". O aditamento foi recebido (fls. 261).

Em alegações finais, por memoriais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido constante na inicial, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A defesa do acusado, em suas alegações finais, requereu preliminarmente o reconhecimento da ilicitude da prova, e no mérito, a absolvição do subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

DECIDO.

No tocante à preliminar, em que pese o esforço da combativa defesa, face ao conjunto probatório não há que se falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, pois conforme restou demonstrado nos autos, os policiais adentraram no imóvel em virtude da fuga do réu, que ao se deparar com os policiais, buscou esconder-se em sua residência, sendo certo que os policiais detinham elementos concretos para compreender presente a situação de flagrância, ante a informação prestada por uma viciada (KALENE) que havia recém adquirido entorpecente no local, indicando com precisão informações sobre o réu, conforme depoimento de fl. 11.

Portanto, vigentes estavam as fundadas razões justificadoras do ingresso no domicílio, ante a patente situação de flagrância, uma das exceções à inviolabilidade constitucionalmente prevista. Evidentemente, o comando contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não configura direito absoluto, notadamente dada a situação concreta de flagrante delito, especialmente em virtude do caráter permanente do delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, fica repelida referida tese defensiva pelos motivos expostos alhures.

Neste sentido, aliás, forte a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E LEI N. 10.826/2003, ART. 12, CAPUT) - PRELIMINAR DE NULIDADE - INVASÃO DE DOMÍLIO - Não há nulidade por violação de domicílio quando o policial adentra à casa do acusado, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, por configurada a situação de flagrante (art. 5º, XI, da CF), notadamente em se tratando de crime de natureza permanente. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS AUTOS -

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria dos delitos. REDUÇÃO DA PENA-BASE - Possibilidade. Dolo normal ao tipo. Penas redimensionadas. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME - Impossibilidade. Deve ser mantido o regime prisional fechado para o crime de reclusão e semiaberto para o apenado com detenção. Tanta a quantidade de drogas e munições apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - Inviabilidade. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante foi condenado à pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. PREQUESTIONAMENTO - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso da defesa parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1525924-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021) (negritei)

Quanto ao mérito, a materialidade do crime atribuído ao acusado resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 15/16), laudo de constatação (fls. 50/53 e fls. 58/61), laudos de exame químico toxicológico (fls. 85/87, 88/91), laudo pericial (fls. 240/242) e pela prova testemunhal.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

Em solo policial, o acusado admitiu o envolvimento tráfico de drogas, relatando que detinha consigo clorofórmio e maconha, sendo que parte do produto iria vender, e outra parte iria consumir. No entanto, negou ter comercializado as porções de maconha encontradas com a mulher abordada pelos policiais.

Em juízo, alterou a versão anteriormente apresentada, afirmando que toda a droga encontrada em sua residência destinava-se ao consumo próprio, sendo que os produtos líquidos destinavam-se à limpeza.

O policial militar Jhonny confirmou todos os fatos narrados na denúncia. Destacou que realizavam patrulhamento de rotina no bairro Jardim Caieiras, sendo que na Rua Salvador Bianchi tiveram suas atenções voltadas para uma suposta usuária, KALENA ROXANA SANTOS, e ao abordá-la, foi perguntado se trazia consigo algo ilícito, momento em que confirmou de plano a posse de duas porções de entorpecentes que acabara de adquirir de um morador daquela mesma rua. KALENA apontou para a casa de numeral 26 e indicou o nome "Marcola", e a partir desse momento foi solicitado apoio de outras viaturas para fazerem diligências no referido imóvel. Ao chegarem ao local, encontraram a pessoa de MARCOS saindo do imóvel, ocasião em que demonstrou nervosismo e imediatamente reingressou na moradia com o propósito de esconder-se. Seguiram no seu encalço e após uma rápida busca encontraram tabletas de maconha, uma pedra de crack, dinheiro em notas e um cheque, uma balança de precisão e cinco frascos de vidro contendo substância líquida. MARCOS teria afirmado que a droga encontrada pertenceria ao PCC.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Wender.

Analisando o teor dos depoimentos, bem como os demais elementos de prova colhidos

durante o tramite do inquérito policial e da instrução processual, a alegação da defesa a respeito da fragilidade das provas não deve ser acolhida, não podendo ser descartada a robustez do depoimento dos policiais, que se mostraram harmônicos e seguros, demonstrando idoneidade.

Ademais, quando coerentes as declarações dos agentes da autoridade, como no caso aqui analisado, não se pode deixar de outorgar habitual valor probatório apenas em razão de sua condição de supostamente possuírem interesse em legitimar seus atos.

Cabe à Defesa provar, com segurança, que tais depoimentos são viciados ou ostentam intenção de prejudicar o réu. Tudo indica que os policiais militares agiram com lisura ímpar e, por certo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função.

Isso porque não se afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão somente na respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, vejamos:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (Habeas Corpus 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).”

De outra sorte, é evidente que o acusado não está obrigado a dizer a verdade, contudo, embora a tese defensiva apresentada no interrogatório venha a sugerir que o entorpecente encontrado destinava-se exclusivamente ao uso próprio, os demais elementos de prova caminham no sentido completamente oposto, pois além da quantidade de droga encontrada não se mostrar condizente com o uso, foi colhido na fase investigativa elemento concreto de venda, não se podendo desprezar o fato de KALENE, usuária que detinha a posse de duas buchas de maconha, ter apontado a figura do réu momentos antes da apreensão da droga, e sua delação foi decisiva para o sucesso da apreensão. No mais, além de tal circunstância, de se observar que na residência foram encontrados diversos materiais compatíveis com a ação de tráfico, tais como a balança de precisão, produtos líquidos comumente utilizados no preparo de drogas, quantia em dinheiro significativa, a tornar pouco verossímil a tese de que a droga não era destinada ao comércio.

Logo, diante de todo o exposto, faz-se imperiosa a condenação do réu, exceto pelo delito previsto no artigo 33, § 1º, da Lei n. 11.343/06, aplicando-se à espécie, e consideradas as circunstâncias em concreto, o princípio da consunção.

Isso porque, embora os tipos penais previstos nos artigos 33, "caput", e 33, parágrafo 1º, da Lei de Drogas, tenham objetos diversos, de um lado reprimindo-se a posse de drogas para fins de tráfico, e de outro, a posse de produtos químicos destinados ao preparo dos entorpecentes para venda, é certo e inquestionável que todos os produtos foram encontrados no mesmo local, em idêntico contexto, e a responsabilização pelas duas condutas implicaria em dupla punição pela prática de crime único, com resultado por demais rigoroso.

A corroborar:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. RECURSOS BILATERAIS. DEFENSIVO. PRELIMINAR. Prova ilícita não caracterizada. Prescindibilidade de mandado judicial por se tratar de flagrante em crime permanente. Supostos vícios ocorridos na fase administrativa que não se projetam na ação penal. Nulidade do feito não configurada. Rejeição. MÉRITO. Absolvição quanto ao tráfico. Inviabilidade. Acervo probatório robusto que dá lastro à condenação. MINISTERIAL. Pretendida procedência quanto ao art. 33, § 1º, I. Impossibilidade. Ausência de materialidade. Ainda que assim não fosse, caracterizaria delito-meio, com aplicação do princípio da consunção. DOSIMETRIA. Penas intocadas. Inaplicabilidade das benesses da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º e do CP, art. 44. Regime fechado preservado. TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS. IMPROVIMENTO GERAL. (TJSP; Apelação Criminal 1500515-55.2020.8.26.0617; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

No mais, não resta plenamente esclarecido se o produto químico destina-se ao preparo de drogas, ou se, em verdade, constitui uma espécie de entorpecente, havendo indicativos de que se trata do denominado "lança-perfume", e portanto, não se enquadraria na figura prevista no artigo 33, § 1º, da Lei n. 11.343.06, reconhecendo-se nesse aspecto a atipicidade da conduta.

Portanto, evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhe é imputado, a procedência parcial da ação penal é a medida de rigor, merecendo, outrossim, a absolvição no que diz respeito à suposta prática do delito previsto no artigo 33, parágrafo 1º, inciso I, da Lei de Drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto às circunstâncias judiciais, tratando-se de réu tecnicamente primário, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de multa 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, embora seja o réu primário e ostente bons antecedentes criminais, as peculiaridades do caso demonstram que não era uma neófito no tráfico de drogas, pois mantinha em sua residência drogas variadas (crack, maconha e "lança-perfume"), petrechos tais como balança de precisão, além de dinheiro e cheque, a indicar que trabalha a serviço de evidente grupo organizado atuante na cidade de Limeira, deixando clara a vinculação com organização criminosa e dedicação a atividades delituosas, o que impossibilita a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, tanto que teria mencionado que as drogas pertenceriam ao PCC.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS QUE, APESAR DE TEREM JUSTIFICADO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NÃO DEFINIRAM A FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO, MAS APENAS IMPEDIRAM O SEU RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que o paciente se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (64 emendas contendo cocaína com peso líquido de 74,3 g; 14 porções de cocaína,

na forma de "crack" com peso líquido de 4 g; 14 trouxinhas de "tetrahydrocannabinol", popularmente denominada de "maconha", com peso líquido de 47,9 g e 2 (dois) frascos que continham 11 ml de tricloroetileno), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante do paciente. Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Outrossim, é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes. (...) VI - A quantidade e a diversidade dos entorpecentes foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, bem como na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, sendo, portanto, consideradas como circunstâncias desfavoráveis, a ensejar a aplicação do regime mais danoso, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 419.489 SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018). (Negritei)

Destarte, fixo as penas do crime de tráfico de entorpecentes em 5 (cinco) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado MARCOS ALVES DE MORAES JUNIOR, a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

ABSOLVO-O da prática do delito previsto no artigo 33, § 1º, da lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade nos moldes do artigo 44, do Código Penal, diante do quantum estabelecido, e considerada a gravidade concreta do crime, que ostenta caráter hediondo.

Quanto ao regime prisional, o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, seja na sua redação original (HC n. 82.959/SP), seja na redação da Lei n. 11.464/2007 (HC n. 111.840/ES), o qual determinava a obrigatoriedade do regime fechado para os condenados por crimes hediondos e os a eles equiparados.

Assim, sendo o réu primário, sem antecedentes e atendendo a pena o requisito objetivo do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, razoável a fixação do regime semiaberto.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União, em especial o o montante em dinheiro.

Com o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Limeira, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA